

EXAME PRÉVIO DE EDITAL
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 05-02-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====

Processos: TC-023300.989.24-1
TC-023298.989.24-5

Representantes: Francisco Sergio Nunes
A S Nascimento Ambiental Serviços Urbanos Eireli

Representada: Prefeitura Municipal de Ilhabela

Assunto: Exame prévio do edital do Pregão Presencial nº 008/2024, do tipo menor preço global, que tem por objeto a *“contratação de empresa especializada na gestão e manutenção de cemitério para execução de serviços de conservação, limpeza, manutenção e realização de procedimentos fúnebres no cemitério Municipal”*.

Responsável: Antonio Luiz Colucci (Prefeito)

Advogados cadastrados no e-TCESP: Eduardo Leandro de Queiroz e Souza (OAB/SP nº 109.013), Graziela Nóbrega da Silva (OAB/SP nº 247.092), Rodrigo Pozzi Borba da Silva (OAB/SP nº 262.845).

=====

EMENTA: EXAME PRÉVIO DE EDITAL. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. SERVIÇOS DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO E DE DOCUMENTOS QUE EMBASEM A ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO. FALTA DE INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO DIMENSIONAMENTO DO OBJETO E ADEQUADA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS. ILEGAL EXIGÊNCIA, PARA FINS DE CONHECIMENTO DE RECURSOS, DA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS AO TÉRMINO DA SESSÃO PÚBLICA. APARENTE RESTRIÇÃO INDEVIDA À LEGITIMIDADE DE QUALQUER PESSOA PARA IMPUGNAR O EDITAL. INJUSTIFICADA ADOÇÃO DA FORMA PRESENCIAL DO PREGÃO. DESCABIDA EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFRONTA

**AO ARTIGO 69, INCISO II, DA LEI Nº 14.133/21. PARCIALMENTE
PROCEDENTE.**

1 - RELATÓRIO

1.1 Trata-se do **exame prévio de edital** do Pregão Presencial nº 008/2024, do tipo menor preço global, elaborado pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHABELA**, cujo objeto é a *“contratação de empresa especializada na gestão e manutenção de cemitério para execução de serviços de conservação, limpeza, manutenção e realização de procedimentos fúnebres no cemitério Municipal”*.

1.2 Insurgiu-se **FRANCISCO SERGIO NUNES** contra os seguintes aspectos do ato convocatório:

- a) ausência de memória de cálculo do valor estimado de R\$ 1.308.334,44, em contrariedade ao disposto no artigo 18, incisos IV e VI, da Lei 14.133/2021;
- b) falta de planilha de custos/despesas demonstrando quais são os gastos mensais/anuais de gestão e manutenção do cemitério municipal;
- c) discrepância entre o subitem 9.5.4.1, que possibilita a comprovação do patrimônio líquido solicitado por meio do balanço patrimonial do último exercício, e o item 9.6, que requer a apresentação dos demonstrativos contábeis dos últimos 2 exercícios sociais;
- d) ausência de informações adequadas para a elaboração das propostas, tais como *“quantos jazigos há no cemitério, quantos estão em uso, quantos estão em estado de abandono, não há informação de quantos sepultamentos são feitos no local por semana/mês/ano, não há informação de qual é o horário de funcionamento do cemitério, quais os dias de funcionamento do cemitério, quantos sepultadores, quantos porteiros há no cemitério, quantos pedreiros há no cemitério, enfim, quais são em número os funcionários que trabalham atualmente no cemitério”*;

- e) disposição editalícia no sentido de *que “não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública” (subitem 12.3.1);*
- f) obscuridade nas cláusulas que tratam da impugnação ao edital, que não deixam claro se *“pode qualquer pessoa fazer a impugnação ou somente o representante legal das pessoas jurídicas interessadas em participar da licitação”;*
- g) estabelecimento, como condição de participação, de que *“as empresas interessadas sejam detentoras de senha para participar de procedimentos eletrônicos junto a Bolsa Brasileira de Mercadorias” (item 3.1);*
- h) o item 6.4¹ não menciona objetivamente o critério de julgamento a ser utilizado; e
- i) falta de informações quanto ao artigo 18, incisos X e XI e artigo 23, incisos III, V, VI, VII, X, XI, XII, XIII e XIV, da Lei 8987/95.

1.3 Por sua vez, **A S NASCIMENTO AMBIENTAL SERVIÇOS URBANOS EIRELI** queixou-se da falta de informações acerca da quantidade de funcionários e metragem mínima mensal para a execução dos serviços a serem prestados.

Apontou que, na visita técnica realizada, *“em nenhum momento o funcionário que a acompanhou, definiu de forma clara, ou ainda respondeu os questionamentos quanto a quantidade necessária ou apresentou ainda metragem que pudesse calcular a necessidade exata dos colaboradores para execução do contrato”.*

1.4 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi decretada liminarmente e referendada por este E. Plenário.

¹ Caso o critério de julgamento seja GLOBAL ou por LOTE, será obrigatória a apresentação de proposta contemplando todos os itens que compõem o(s) lote(s).

Na oportunidade, foram solicitados esclarecimentos acerca da adoção da forma presencial do pregão, em descompasso com o artigo 17, § 2º, da Nova Lei de Licitações, que estabeleceu o uso preferencial do meio eletrônico.

De igual modo, foi requisitada explicação sobre a exigência de certidão negativa de concordata (recuperação judicial)², por exceder o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

1.5 Notificada, a **Administração** defendeu ter sido a memória de cálculo elaborada com fulcro *“na estimativa de custo de acordo com os profissionais relacionados a execução dos serviços prestados, considerando para tanto, a base salarial de cada categoria, não sendo incluída a quantidade de funcionários para evitar ingerência contratual”*.

Ressalvou que os custos *“não podem ser auferidos com precisão”*, eis que o montante global, *“distribuído entre os servidores e custos com materiais de construção, bem como, equipamentos, dependem dos valores específicos das licitações relacionadas a cada produto”*.

Argumentou inexistir a discrepância suscitada entre o subitem 9.5.4.1, que possibilita a comprovação do patrimônio líquido solicitado por meio do balanço patrimonial do último exercício, e o item 9.6, que requer a apresentação dos demonstrativos contábeis dos últimos 2 exercícios sociais.

Sustentou que *“entre os jazigos, ossários e gavetas, foi informado que há aproximadamente 2.150 locais, onde, cerca de 90% estão em uso, não estando nenhum dos itens mencionados em estado de abandono, mas sim com necessidade de manutenções e eventuais reformas”* (sic).

² 9.5.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial (concordata) expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial expedida pelo domicílio do empresário individual.

9.5.2. Nos casos de recuperação judicial e extrajudicial deverá apresentar Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, bem como seu respectivo cumprimento, sem prejuízo do atendimento de todos os outros requisitos de habilitação estabelecidos neste edital, conforme dispõe a Súmula nº 50 do TCESP.

a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida pelo distribuidor do domicílio da licitante, expedida com data não superior a 30 (trinta) dias;

Explicou, também, que *“o quantitativo mensal de sepultamentos é em média de 26, e o horário de funcionamento do cemitério, ocorre de segunda a segunda 24 horas por dia, das 8:00 às 17:00 para sepultamentos e visitas, e o restante dos horários, para velório. O local conta com 8 colaboradores, sendo 1 coveiro, 1 administrativo e 6 auxiliares de serviços gerais”*.

Disse que tais informações seriam de fácil obtenção, não acarretando qualquer prejuízo concreto à competitividade.

Expôs que o subitem 12.3.1 *“indica que as manifestações quanto a interposições de recurso devem ser motivadas, visto que deve ser apresentada no momento da manifestação de interesse para interposição de recurso, já que se trata de medida cautelar que busca garantir o procedimento adequado da licitação, diminuindo a incidência de recursos apresentados de natureza meramente protelatória ou ainda com intuito de tumultuar o torneio”*.

Afirmou que *“o item 2.2 do edital torna nítido que qualquer pessoa poderá impugnar o edital, sendo que o subitem 2.2.1 indica que a impugnação deverá estar assinada por representante legal. Os subitens seguintes tratam acerca dos documentos necessários, que devem acompanhar a peça de impugnação para logicamente demonstrar quem de fato está impugnando o edital, ou, em nome de quem”*.

Anotou que o dispositivo que menciona a necessidade de senha para participar do procedimento constitui mero erro formal, pois a licitação é no formato presencial.

Em relação ao critério de julgamento, destacou que o edital dispõe no preâmbulo e no Termo de Referência que a adjudicação será pelo menor preço global.

Além disso, consignou que o certame não se destina à concessão do cemitério municipal, mas a simples prestação de serviços para as atividades descritas no termo de referência.

Por fim, aduziu que *“toda e qualquer resposta apresentada durante a visita técnica, teve como princípio os conhecimentos da colaboradora responsável pelo local, mas, quaisquer outras informações mais detalhadas,*

conforme informado pela colaboradora, poderia ter sido obtida por meio de contatos a secretaria responsável pela contratação”.

1.6 O Ministério Público de Contas manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Assentiu com a Representante quanto à ausência de memória de cálculo e de planilha de custos, destacando inexistir no *“Termo de Referência preços unitários referenciais e memórias de cálculo, abrangendo, por exemplo, as categorias profissionais consideradas (e as respectivas bases salariais), ou os custos individualizados relativos a veículos, equipamentos, despesas administrativas, entre outros”*.

No mesmo sentido, consignou que o edital não apresenta qualquer informação que permita dimensionar os recursos necessários à gestão do cemitério.

Além disso, apontou que, nos termos do artigo 165, §1º, inciso I, da Lei nº 14.133/2017, *“apenas a intenção de recorrer deve ser manifestada ao término da sessão, sob pena de preclusão, não sendo necessário que se indique, de imediato, as razões recursais”*.

Igualmente, considerou que a exigência de assinatura do representante legal nas impugnações ao edital *“é imposição incomum em licitações e, de fato, parece restritiva, uma vez que artigo 164 da Lei nº 14.133/2017 permite que qualquer pessoa apresente impugnação ao edital, inclusive pessoas físicas, não exigindo representação legal”*.

Anotou ser incontroversa a crítica à exigência de senha, falha reconhecida pela Administração.

Ponderou que, inobstante o preâmbulo do edital indique o critério de julgamento, pertinente que promova a adequação no item 6.4 do edital.

De outro modo, afastou as críticas direcionadas aos requisitos de habilitação econômico-financeira, bem como à inobservância da Lei nº 8.987/95.

Quanto aos aspectos suscitados de ofício, entendeu não terem sido apresentadas justificativas hábeis a demonstrar *“obstáculo específico e objetivo*

decorrente da utilização da forma eletrônica na presente contratação, tampouco inviabilidade técnica que impossibilite seu emprego”.

Ademais, ressaltou que a exigência de certidão negativa de recuperação judicial para fins de habilitação econômico-financeira extrapola as previsões do artigo 69 da Lei nº 14.133/21.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 A Prefeitura Municipal de Ilhabela pretende a *“contratação de empresa especializada na gestão e manutenção de cemitério para execução de serviços de conservação, limpeza, manutenção e realização de procedimentos fúnebres no cemitério Municipal”*.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 Inicialmente, afasto a crítica relacionada à falta de informações previstas nos artigos 18 e 23 da Lei nº 8.987/95, pois o certame não se destina à concessão dos serviços funerários, mas apenas à contratação de empresa para prestação de serviços de gestão e manutenção do cemitério municipal.

2.3 De igual forma, não subsiste a aventada discrepância entre o subitem 9.5.4.1, que possibilita a comprovação do patrimônio líquido solicitado por meio do balanço patrimonial do último exercício, e o item 9.6, que requer a apresentação dos demonstrativos contábeis dos últimos 2 exercícios sociais.

Tais dispositivos constituem requisitos distintos de habilitação técnica, encontrando-se em conformidade com o que dispõe o § 4º, no primeiro caso, e o inciso I, no segundo, ambos do artigo 69 da Lei nº 14.133/21.

2.4 Não obstante tais aspectos favoráveis, procedem as demais impugnações.

Ainda que a Administração alegue ter elaborado memória de cálculo, afirmou que os dispêndios não podem ser aferidos com precisão, aduzindo que o montante global, *“distribuído entre os servidores e custos com materiais de construção, bem como, equipamentos, dependem dos valores específicos das licitações relacionadas a cada produto”*.

Conforme observou o MPC, *“o edital e seus anexos apenas indicam, de forma consolidada, que o valor estimado da licitação é de R\$ 1.308.334,68 (incluindo todos os serviços que compõem o objeto), não apresentando, entre os seus apêndices, documento que detalhe a forma como o montante foi obtido”*.

Nesse aspecto, como bem destacou o Órgão Ministerial, *“a contratada será responsável não só pelo fornecimento da equipe, mas também pela disponibilização de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e insumos necessários para a execução dos serviços (item 7.22)”, não havendo “no Termo de Referência preços unitários referenciais e memórias de cálculo, abrangendo, por exemplo, as categorias profissionais consideradas (e as respectivas bases salariais), ou os custos individualizados relativos a veículos, equipamentos, despesas administrativas, entre outros”*.

Assim, nos termos do que preceitua o artigo 6º, inciso XXIII, alínea “i”, da Lei nº 14.133/21 deve o termo de referência apresentar *“estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado”*.

2.5 Além disso, confirmada pela instrução a ausência de dados necessários para que as interessadas possam dimensionar os serviços a serem prestados e adequadamente elaborar suas propostas.

Nesse sentido, na oportunidade da concessão da medida liminar, *“pesquisa realizada por meu Gabinete, na página oficial do Município, constatou a existência de diversos pedidos de esclarecimentos acerca primordialmente da falta de informações no edital. Ao respondê-los, a Administração limitou-se a informar que “a visita técnica agendada tem como objetivo verificar as condições locais para a execução do objeto da contratação, permitindo aos interessados verificarem localmente as informações que julgarem necessárias para a elaboração de sua proposta, de acordo com o próprio interessado julgar pertinente, e não cabendo à Administração nenhuma responsabilidade em função de insuficiência dos dados levantados por ocasião da visita técnica”.*

No entanto, a segunda Representante afirmou que nem sequer na vistoria conseguiu obter as informações pertinentes.

Sobre o tema, anotou o MPC que *“o Termo de Referência não apresenta qualquer informação que permita dimensionar os recursos necessários à gestão do cemitério, como a quantidade média de sepultamentos diários, a quantidade de jazigos do cemitério, horário de funcionamento, área total do cemitério, área em que serão realizados os serviços de roçagem (mecânica ou manual), entre outros, informações essenciais à adequada formulação das propostas”.*

Destarte, deve ser aprimorado o Termo de Referência, de forma a consignar todas as informações pertinentes ao objeto e que impactem seu dimensionamento e a adequada elaboração das propostas.

2.6 Outrossim, com a instrução, entendo que deve ser revisto o subitem 12.3.1, pelo qual *“não serão passíveis de apreciação os motivos expostos em memoriais que não tenham sido alegados no ato da manifestação na sessão pública”*, pois o artigo 165, § 1º, da Lei nº 14.133/21 apenas estabelece *“que a intenção de recorrer deve ser manifestada ao término da sessão, sob pena de preclusão, não sendo necessário que se indique, de imediato, as razões recursais”.*

2.7 No que tange à eventuais impugnações ao edital, considero que as cláusulas podem, de fato, conduzir a interpretações divergentes quanto à legitimidade para sua apresentação, devendo ser aperfeiçoadas para consignar de forma clara que *“qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos”* (artigo 164, caput, da Lei nº 14.133/21).

Ademais, bem ressaltou o MPC que *“a exigência de assinatura do representante legal nas impugnações ao edital (que também devem ser acompanhadas dos documentos de que trata os itens 2.2.1.1, 2.2.1.2 e 2.2.1.3) é imposição incomum em licitações e, de fato, parece restritiva”*.

2.8 Além disso, o artigo 17, § 2º, da Lei nº 14.133/21 estabelece o uso preferencial da forma eletrônica nas licitações, sendo *“admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada”*.

No caso, anotou o MPC que *“as justificativas contidas no edital são genéricas e denotam apenas presunção de vantagem da forma presencial sobre a eletrônica, não demonstrando obstáculo específico e objetivo decorrente da utilização da forma eletrônica na presente contratação, tampouco inviabilidade técnica que impossibilite seu emprego. Pelo contrário, em simples consulta ao site da Prefeitura de Ilhabela é possível notar a realização de mais de 120 pregões no formato eletrônico só no ano de 2024”*.

Destarte, na linha do decidido por este Plenário em sessão de 03-07-24³, considero que *“a falta de justificativas suficientes para a utilização da forma presencial no presente caso impõe o reconhecimento da procedência da representação”*.

³ TC-011987.989.24-1. Relator Conselheiro DIMAS RAMALHO.

2.9 Ademais, deve ser excluída a exigência de certidão negativa de recuperação judicial, eis que ultrapassa o disposto no artigo 69, inciso II, da Lei nº 14.133/21.

2.10 Por fim, a despeito de ser possível inferir da leitura do edital que o critério de julgamento eleito é o de menor preço global, assim como patente é o erro material consubstanciado na exigência de senha de acesso, deve a Administração, aproveitando-se das demais correções que deverá realizar no ato convocatório, eliminar as falhas relacionadas a esses tópicos.

2.11 Posto isto, circunscrito às questões analisadas, considero **parcialmente procedentes** as impugnações, determinando que a Administração adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) disponibilizar no Termo de Referência, nos termos do artigo 6º, inciso XXIII, alínea “i”, da Lei nº 14.133/21, as estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte;
- b) aprimorar o Termo de Referência, consignando todas as informações pertinentes ao objeto e que impactem seu dimensionamento e a adequada elaboração das propostas;
- c) adequar o subitem 12.3.1 ao que prescreve o artigo 165, § 1º, da Lei nº 14.133/21;
- d) consignar de forma clara que qualquer pessoa é parte legítima para impugnar edital de licitação ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, deixando de impor os documentos previstos nos subitens 2.2.1.1 e 2.2.1.2;
- e) adotar a forma eletrônica de pregão, ou justificar adequadamente a opção pelo formato presencial;
- f) excluir a exigência de certidão negativa de recuperação judicial; e
- g) corrigir as cláusulas relacionadas ao critério de julgamento e à exigência de senha para participação no procedimento.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 05 de fevereiro de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
CONSELHEIRO